Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Número do	1.0079.15.056165-6/001	**Númeração**	0561656-
Relator:	Des.(a) Pedro Vergara		
Relator do Acordão:	Des.(a) Pedro Vergara		
Data do Julgamento:	01/08/2017		
Data da Publicação:	09/08/2017		

EMENTA OFICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - TESTEMUNHA DE OUVIR DIZER - PROVA INSUFICIENTE - IN DÚBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO. 1. Impõe-se a absolvição quando inexiste prova da participação do apelante na prática delitiva, havendo apenas o reconhecimento fotográfico e testemunha de ouvir dizer, devendo ser observado o princípio do in dúbio pro reo. 2. Recurso provido.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0079.15.056165-6/001 - COMARCA DE CONTAGEM - APELANTE(S): ADELSON CABRAL GOMES - APELADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - VÍTIMA: A.V.A.S., D.P.S., P.S.O.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em DAR PROVIMENTO.

DES. PEDRO COELHO VERGARA

RELATOR.

DES. PEDRO COELHO VERGARA (RELATOR)

V O T O

I - DO RELATÓRIO - Cuida-se de AÇÃO PENAL PÚBLICA promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra ADELSON CABRAL GOMES como incurso nas sanções do artigo 157 § 2º I do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 05 de Dezembro de 2015 por volta das 20:00 horas no local conhecido por Rua Ônix nº 07 Bairro Arvoredo na Comarca de Contagem o apelante mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo subtraiu para si um veículo e um aparelho celular de propriedade da vítima Davidson Paulo de Souza Mayrink tudo conforme consta do anexo inquérito policial [f.01D-02D].

Recebida a denúncia o apelante foi citado e apresentou defesa preliminar às f. 143-153 [f.155 e 154].

As testemunhas arroladas foram ouvidas, interrogado-se o apelante, nada requerendo as partes em diligência [f.188, 245 e 246-147].

O Órgão Ministerial pede nas alegações finais a condenação, rogando a defesa a absolvição [f.248-252 e 256-266].

Proferida a sentença o apelante foi condenado nas sanções do artigo 157 § 2º inciso I do Código Penal à pena de 05 [cinco] anos e 04 [quatro] meses de reclusão e ao pagamento de 13 [treze] dias-multa sobre 1/30 [um trigésimo] do salário mínimo vigente à época do fato no regime semiaberto [f.268-270].

Inconformada com a decisão recorreu a defesa objetivando a absolvição ou o afastamento da causa de aumento do emprego de arma, rogando o Parquet o desprovimento do pleito, manifestando a Procuradoria-Geral de Justiça pelo parcial provimento do recurso [f.278-287, 288-291 e 301-303v].

É o breve relato.

- VOTO -

II - Da admissibilidade - Conheço do recurso já que presentes estão os pressupostos para sua admissão.

III - Das preliminares - Inexiste na espécie qualquer nulidade ou causa de extinção da punibilidade.

IV - Do mérito - Cuida-se de delito de roubo majorado cuja norma penal incriminadora se encontra insculpida no artigo 157 § 2º inciso I do Código Penal.

Resume-se a questão à análise da possibilidade de absolvição ou de afastamento da majorante do emprego de arma.

Do pedido de absolvição - A defesa pede a absolvição por ausência de prova.

Razão lhe assiste.

A materialidade se encontra comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de f. 02-08, pelo Boletim de Ocorrência de f.12-21, pelo Auto de Apreensão de f.36 e pela prova testemunhal colhida.

A autoria todavia não restou comprovada, inexistindo elementos suficientes a justificar uma condenação.

O apelante negou a prática delitiva tanto na fase inquisitiva como em juiz, alegando que o carro furtado estava na posse de um terceiro não abordado Adilson dos Santos Gonçalvez como se lê à f.08 e 246-247.

A vítima Davidson Paulo de Souza Mayrink reconheceu o apelante na fase inquisitiva mas por meio fotográfico, a saber:

"[...] que ontem, pela manhã, o declarante recebeu uma ligação oriunda da PM, dizendo que o veículo do declarante havia sido recuperado, sendo que foi apresentada a fotografia de um suspeito; que o declarante de plano e sem titubear reconheceu Adelson Cabral Gomes como autor do crime no qual foi vítima; que nesta ato, mostrada a fotografia de Adelson Cabaral Gomes, misturada ao meio de outros investigados, o declarante novamente o reconheceu sem sobra de dúvidas como sendo ele (Adelson) o autor do crime no qual figura como vítima; [...] que também faz constar que Adelson Cabral agiu sozinho no dia dos fatos [...]" [f.42] [grifei].

O auto de reconhecimento acostado à f. 43 confirma o reconhecimento por meio de foto.

Referido reconhecimento não foi por sua vez confirmado em juízo eis que a vítima não foi ouvida em razão de seu falecimento.

O policial Marcelo Dias Camargos reproduziu ainda apenas o que foi narrado pela vítima, confirmando o reconhecimento fotográfico, o que constitui prova demasiadamente indireta para uma condenação.

Este esclareceu na fase inquisitiva que o veículo subtraído se apresentava como de propriedade do terceiro não abordado Adilson dos Santos Gonçalves, havendo uma identidade deste dentro do carro, assim se manifestando:

"[...] que, quando foi informado do valor da conta, um dos ocupantes do quarto alegou que não tinha a quantia para o pagamento e que iria se deslocar ao banco para sacar o dinheiro, deixando as outras quatro pessoas no estabelecimento, bem como o veículo de sua propriedade; [...] que no estacionamento do quarto 07, depararam com o veículo Honda City [...] e no seu interior quatro pessoas, sendo Adelson Cabral Gomes [...] que o referido veículo está com sinalização de roubo [...] que no interior do veículo foi localizada a Carteira de

Identidade [...] titular Adilson dos Santos Gonçalves; que conforme versão dos abordados, eles se encontravam no aglomerado Bispo de Maura, bairro Nova Pampulha, em um baile funk, quando, por volta de 05hs30min, foram convidados por Adilson, o qual conhecia apenas o conduzido Adelson Cabral, para que juntos fosse para um motel [...] que eles alegam que não tinham conhecimento que o veículo era roubado, uma vez que Adilson se apresentara como proprietário do automóvel; [...]" [f.02-02v] [grifei].

Fê-lo também em juízo, salientando ainda que a vítima reconheceu o apelante primeiramente por meio de uma foto enviada via whatsapp, o que macula mais o suposto reconhecimento, a saber:

"[...] que, no dia dos fatos, empenhado a tanto, compareceu ao motel mencionado na denúncia e ali, se inteirando dos fatos, descobriu que o Honda Civic referido nos autos era roubado; que conseguiu, então, contato com o proprietário do automóvel e com a mulher dele, para os quais via whatsapp, remeteu ao casal fotográfica do acusado presente, tendo o referido casal, então, confirmado que o acusado se tratava de um dos dois meliantes que lhe assaltaram, subtraindo o veículo em questão; [...]" [f.245].

Há ainda contradição no depoimento do referido policial eis que este alegou que a vítima reconheceu o apelante como um dos autores, sendo que esta alegou que o agente agiu sozinho, inocorrendo ainda reconhecimento no local para onde o apelante foi levado nos termos salientados pelo miliciano, pois, este, ocorreu, apenas por foto.

As menores - M.G.O. e D.I.S.E.C. - que estavam no motel onde o apelante e o veículo roubado foram encontrados, afirmaram ademais que Adilson dos Santos Gonçalves dirigia o carro, agindo como proprietário, conforme se lê à f.06 e 07.

A única testemunha que alega que o apelante dirigia o veículo é a testemunha Poliana da Silva Oliveira - f.04 -, restando todavia seu depoimento isolado, tendo esta ainda narrado o que ouviu de outra funcionária, não podendo esta ter assim certeza de sua alegação

conforme se observa à f.188-189.

O reconhecimento fotográfico, a dúvida sobre quem estava na posse da res furtiva e as provas indiretas, portanto, a meu ver, não podem fundamentar um decreto condenatório.

Este é o entendimento doutrinário:

"[...] O reconhecimento fotográfico não poderá, jamais, ter o mesmo valor probatório do reconhecimento de pessoa, tendo em vista as dificuldades notórias de correspondência entre uma (fotografia) e outra (pessoa), devendo ser utilizado este procedimento somente em casos excepcionais, quando puder servir como elemento de confirmação das demais provas. [...]" [Oliveira, Eugênio Pacelli de, Curso de Direito Penal, 6ª ed. rev., Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 365].

"[...] Questiona-se na jurisprudência o valor legal do reconhecimento por meio de fotografias, chegando-se a afirmar numa corrente extremada que não é ele meio de prova contemplado do Código. Entretanto, a opinião prevalente é a de que o reconhecimento fotográfico é uma prova inominada, como outras não previstas expressamente na lei, que pode e deve ser considerada. Deve ser utilizada, porém, apenas quando não é possível o reconhecimento pessoal. Por ter valor relativo e possuir caráter precário, que pode conduzir a um lamentável engano, o reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a decisão condenatória, mas pode, corroborado por outros elementos, ser decisivo para uma sentença desfavorável ao réu. [...]" [Mirabete, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed. - São Paulo: Atlas, 2000, p. 520].

Este é o entendimento jurisprudencial:

"PENAL - ROUBO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES - ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO - INSUFICIÊNCIA PARA A

CONDENAÇÃO - PROVAS JUDICIALIZADAS FRÁGEIS E INDIRETAS - ABSOLVIÇÃO - IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO. A limitação moderada em relação aos elementos informativos colhidos na fase inquisitiva, há muito acolhida na jurisprudência pátria, faz-se hoje expressamente prevista na legislação processual penal vigente diante das alterações introduzidas pela Lei nº 11.690/08, que deu nova redação ao art. 155 do CPP. Embora se deva dar crédito ao testemunho policial, o mesmo constitui prova demasiado indireta para uma condenação se o policial não presenciou os fatos e apenas ratificou a versão extrajudicial da vítima, a qual, por sua vez, não foi ouvida em juízo. É de se invocar a prevalência da dúvida se as provas judicializadas são frágeis e indiretas, devendo prevalecer, neste caso, a solução absolutória à luz do princípio do in dubio pro reo." [Apelação Criminal nº 1.0024.01.592278-4/001, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez - TJMG - data da publicação 06/08/2010].

A primariedade do apelante conforme CAC de f.103 e as circunstâncias da sua abordagem e de seu reconhecimento devem ser assim observadas em seu favor.

Inexistindo desta forma nos autos prova estreme de dúvida para a condenação, a absolvição é medida que se impõe em observância ao princípio do in dubio pro reo.

Este Tribunal já se manifestou nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA DE UM DOS CORRÉUS - NULIDADE ABSOLUTA - PROCESSO ANULADO EM RELAÇÃO A ESTE ACUSADO - PREFACIAL ACOLHIDA - MÉRITO - AUTORIA DE UM DOS AGENTES NÃO DEMONSTRADA DE MANEIRA IRRETORQUÍVEL - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - RECURSO DA DEFESA PROVIDO, PREJUDICADO O MINISTERIAL. [...] II - Um decreto condenatório somente é possível diante de um juízo de certeza moral. Se a prova dos autos não gera a convicção necessária sobre a prática do delito pelo acusado, impõe-se sua absolvição pelo princípio do 'in dubio pro reo'. III - Recurso da defesa provido, prejudicado o ministerial. [Apelação Criminal nº

1.0441.05.000458-5/001 - Rel. Des. Eduardo Brum, data da publicação 03/09/10].

Cabendo o ônus da prova ao Ministério Público e não se desincumbindo este da prova da autoria a melhor solução é a aplicação do NON LIQUET.

Magalhães Noronha leciona sobre o tema:

"[...] Do ônus da prova. A prova da alegação incumbe a quem a fizer, é o princípio dominante em nosso Código. Oferecida a denúncia cabe ao Ministério Público a prova do fato e da autoria; compete-lhe documentar a existência concreta do tipo ("nullum crimem sine typo") e de sua realização pelo acusado. [...] Este também tem a seu cargo o anus probandi. [...]. Vê-se, pois, que o ônus da prova cabe às partes. Há uma diferença, porém. A da acusação há de ser plena e convincente, ao passo que, para o acusado, basta a dúvida." [...]" [in Curso de Direito Processual Penal, 6ª ed. São Paulo: 1973, p.88-89].

Absolvo desta forma o apelante das sanções do artigo 157 § 2º inciso I do Código Penal nos termos do artigo 386 inciso VII do Código de Processo Penal.

V - Do provimento - Ante o exposto DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Sem custas.

DES. ADILSON LAMOUNIER (REVISOR) - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. EDUARDO MACHADO - De acordo com o(a) Relator(a).

SÚMULA: "DERAM PROVIMENTO"